

Preface

© 版权所有，未经授权不得转载转售，违者必究

华东政法大学法律学院 24010102016

- 不是法考培训班；不是普法培训班。是学科性系统课程，需要有完整系统理论。
- 对象：宪法——解决法律纠纷，分析研究法律现象，调整人的行为规则（不是政治性的）

导论

一、宪法学能为我们做什么？

什么是宪法（现象）问题？

必须是由宪法来解决的。比如 立法（如民法典的制定）、国家决策政策、两会（做工作报告、审议等）。

当一个问题纳入到某个法律，那这个问题就是该法律调整的对象。

《宪法》第13条【财产权】 公民的合法的私有财产不受侵犯。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。「当公民个人财产被征收征用时，就涉及到宪法问题。」

| 课堂上老师定立规则要把手机调成静音，有人违反，老师要把手机收走
· 一旦立法主体立了法律，为了避免规则被违反，则立法主体需要有监督权和惩罚权「否则立法立的没有意义」。

· 反驳：立法权哪来的，谁有立法权？——国家（公权力）

进一步：国家可不可以随便拿？——不可以。对于第13条必须三个条件每一个都符合（公共利益的需要；法律；补偿）。

→法律：全国人大及其常委会制定的法律、国务院制定的行政法规

所以课堂的规则是没有实质上的有效性的。但是定立该规则的目的是相互尊重，提醒良好的课堂秩序。

| 个人的杯子需要被征用，但是我拒绝政府的征用，最终可能会怎么样？
· 最后可能会 强制征收占用——政府是公权力机关，有强制权。

此时财产权侵权，怎么寻求救济？

· 走行政诉讼。——行政诉讼被告一定是行政机关。

行政问题就是宪法问题，行政法又被称为“小宪法”，二者高度相同。

如果拿走杯子的是人大、法院、监察委员会、党委等呢？

· 三个诉讼没有一个诉讼能帮助你，因为以上的机关都不是行政机关。

· 上访也无法解决，所以如果有宪法诉讼等宪法监督机构，这个机制就能解决——因为这是一个宪法问题。

综上，什么样的问题是宪法问题？

如果是宪法法律问题，一定有一方法律主体是国家公权力。

公民最害怕来自国家的侵权，因为国家公权力的机关是国家暴力统治的工具。而当宪法越有用，公民的恐惧感就越会降低。

2023年中国十大宪法事例（中国人大法学院）：

- 法工委就涉罪人员近亲属受限制规范进行合宪性审查
- “异地用检”得到进一步规范
- 全国人大常委会通过《关于完善和加强备案审查制度的决定》
- 未成年人因文身被取消入学资格
- 《治安管理处罚法》修订草案引起热议

| 禁止在公共场合佩戴、穿着有损民族精神、伤害民族情感的物品。

· 什么是民族精神、民族情感，什么是“有损、伤害”？

比如有公民穿和服站在樱花树下拍照，另一个公民报警说这伤害了我的民族情感。一个痛恨日本的警察来了就把他抓起来，另一个无所谓的警察来了就觉得没啥。

问题：给了执法人员极大的自由裁量权。

但是不赞成这种条款，不代表没有界限，不代表不能制裁。

比如在毛泽东纪念堂举一个蒋介石会标，南京大屠杀纪念馆专门穿木屐。这时候执法人员就可以执法。

所以，不写进去也能制裁。写进去就是给了一把“剑”，扩大了其自由裁量权。

| 执法过程不能谩骂、侮辱执法人员，如果谩骂、侮辱执法人员造成执法障碍的，从重处理。

执法难恰恰说明了中国法治的进步——掌握公权力的人说一不二的时候才是法治落后的时候。「“敢和国家公权力对视了”就是好的法治状态」

· 什么是谩骂和侮辱？

比如违章停车下执法人员不听辩解，驾驶员忍不住说了一句脏话，执法人员就说其违规罚款（争执过程中语气稍微冲了一些）。其导致的结果是：以后遇到执法人员，只能说“好好好”。

执法人员确实不能被谩骂侮辱，但是制定法律也要看谩骂侮辱了什么、程度又是什么。

比如农民将执法人员推进粪坑，这毋庸置疑应当从重处理。

- 多项优化营商环境的政策密集出台
- 多项生育相关事例引起关注
- 部分基层政府违法整治行动引起关注
- 湖南省衡阳市“政务数据第一拍”
- 全国人大常委会首次围绕同一主题对“一府两院”报告开展专题询问

有关事件

拆迁的历史

政府大楼铺张浪费——财政—预算（标准的宪法问题）

中国纳税人的钱花到哪里去了？——一个严肃而严重的宪政问题！

二、宪法学点什么？怎么学？

（一）宪法学的内容呢体系

1. 宪法的基本理论（教材第1、5章）
2. 宪法的基本内容（宪法143条文本；教材第2、3、4章节）

（1）权利

（2）权力

（二）怎么样学好宪法学课程

读教材、听讲授、记笔记、参考书、背法条、读案例（睁开眼睛看社会）

三、宪法的历史发展（第一章 第二节）

大前提：特指近代宪法——从西方先行。（如果说“宪法”两个字，中国古代和西方古代都有）近代宪法核心理念：对于国家权力的配置和控制、对于公民权利的保障。

（一）起源——资本主义国家宪法道路

经济条件——市场经济的确立和发展

政治条件——资产阶级民主制度的产生

社会条件——政治国家于市民生活合意的分离

思想条件——资产阶级启蒙思想运动

* 与资产阶级革命紧密相连——宪法是资产阶级革命的产物。最早资产阶级革命是荷兰，但是最早产生宪法的国家是英国——说明条件的发展是一个过程，只有积累才能量变到质变。

1. 英国宪法的产生与发展

英国是近代宪法的诞生地。“宪法之母”/“宪政之母”

《自由大宪章》虽然不是近代意义上的宪法性法律（封建专制社会时期，是和新兴资产阶级订立的协议——所以从形式和内容上都不具备宪法的特质），但其所确立的体制直接影响着近代英国的宪政体制。实质上，所以它是英国的第一个宪法性文件。

英国宪法的显著特点：不成文性。（不是说没有文字，是在描述宪法的分类和特点时，该国的宪法没有集中在一个独立的文本上，如宪法典。）

2. 美国宪法的产生与发展

美国宪法是世界第一部成文宪法典。“世界宪政史上第一部宪法典”——把所有内容放在一个宪法文本上。

于1787年通过，1788年正式成立。中间的时间差体现了「制宪权」的问题——制宪会通过宪法不代表宪法有效，还需要人民投票 由州议会批准生效。该宪法体现了单一制联邦制国家下的统一：这部宪法是用来规范美国联邦的，在此之前没有联邦，只有13个州的邦联组织，不属于独立完整主权的国家。（美国政府是1789年建立的——时间线说明：**宪法是一个设计配置国家政府的法律**）

结构：由简短序言（72字）与7条正文组成，迄今为止，共批准颁布了27条宪法修正案。| 逻辑安排上他们按照每一个条文一件事讲清来排，所以内容也很多。| 迄今为止，美国宪法还在继续用。1791年到今天只修改了十条。重点其实在于**美国联邦最高法院对于宪法的解释**。

3. 法国宪法的产生与发展

法国是欧洲大陆最早制订成文宪法典的国家。（“不说欧洲”——有英国，再解释很麻烦）

宪法之前，1789年制宪会议通过《人权与公民权利宣言》（简称人权宣言）是法国资产阶级革命中提出的第一个宪法行纲领性文件。（不同于英国，该文件具备宪法要素、内容，并且后来也被用于宪法典中）（马克思形容世界上第一份人权宣言：独立宣言）

1791年批准生效的宪法为法国宪法历史上第一部宪法，它以《人权宣言》作为序言。法国现在适用的是1958年宪法，中间经过了多次修改，并且在1791-1958年中也是多次修改。（法国宪法修改也很频繁，但是没有人会否认法国在宪法上的成就 所以更重要的是应该修改什么、修改的内容中对于中国发展有必要的是什么）

（二）中国宪法

和其他国家的宪法有交叉。以1949年为界限，分为旧中国和新中国。

1. 旧中国的立宪活动

（1）清末“预备立宪”

成果是1908年《钦定宪法大纲》，属于君主立宪，具备了一定的宪法因素。但是本质上只是清朝政府做做样子，并没有改革的决心。同时期，中国资产阶级革命爆发，清朝1911年颁布《十九信条》垂死挣扎，但是仍然没有遏制住，最终爆发辛亥革命。

（2）民国初年的立宪

制定第一部《中华民国临时约法》，内容设计上是内阁制的政治体制（类似于德国「不是英国，英国内阁制有皇帝」）。目的一个是设计中华民国的政治体制，另一个是让袁世凯做总统时能够被约束权力。

(3) 北洋军阀时期的立宪——袁世凯上台后

袁世凯上台后，将中华民国临时约法立刻废除，制定了《中华民国约法》。所设计的体制就是总统制，并且将总统权力放到无限大。但是他仍然不满足，只想要做皇帝复辟，最终做了83天后死亡。

袁世凯死后，陷入北洋军阀的混战。就成为了“一个军阀上台就一部宪法制定”的情况。但是曹锟在1923年操控国会，颁布了中国历史上第一部正式的宪法《中华民国宪法》。但是这部宪法没有实施，因为它是通过贿赂才通过的——“贿选宪法”。

(4) 南京国民政府时期的立宪

1928年，蒋介石在形式上统一中国，建立南京国民政府。蒋介石上台并不立宪，说孙中山提出：想要立宪有两个条件——先“军政”后“训政”（训老百姓当家做主——宪法的本质就是人民主权）再“宪政”。所以蒋介石上台先确定了“训政”时期的规则纲领，是一个“一党治国”的本质态度。

1931年9月18日后，迫于社会压力，蒋介石说：训政结束，开始制定宪法。于1933年建立宪法制定委员会，草案于1936年的五月出来了——“五权宪法”。

但是1937年抗日战争开始，社会环境不稳定了，阻断了宪法的历程，直到1945年战争结束，1946年这一部宪法最终通过——《中华民国宪法》，1947年1月1日宪法生效。但是同时国内环境变化，国共第三次战争（解放战争）。那么这部宪法在中国大陆上就没有实施过——可以说蒋介石统治下的中国宪法一天都没有落地过。

但是这一部1946年《中华民国宪法》今天还在台湾地区实施，即“五权宪法”。

2. 新中国的立宪活动（自学宪法修正案）

(1) 共同纲领——具有根本性质的临时宪法

1949年9月，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过。

规定了我国一些根本制度、根本问题，但是不是宪法。

同时期配套的有《中央人民政府组织法》，配置了当时我国权力运行的机制。所以共同纲领和该组织法综合在一起才有宪法特性。

当时，也没有中国人民代表大会，是中国人民政治协商会议履行了中国人民代表大会的职权。

(2) 1954年宪法——中华人民共和国第一部宪法、中国历史上第一部社会主义宪法

| 该宪法是社会主义宪法，参照的是前苏联。当时成立了中华人民共和国宪法起草委员会。

通过原因：①内因：中国的政治、经济形势变化②外因：前苏联斯大林力荐——宪法的必要性在于政权合法化，即让当时政府替代蒋介石政府被世界接受——关键在于该政权是人民产生——用宪法确立这些根本问题。

| 1954年宪法，1953年启动。毛泽东在西湖边琢磨了两个半月——“毛泽东宪法”“西湖宪法”。

| 1954年宪法选择的是联合政府制度。主席+副主席，副主席都是各个民族党派的，体现了当时中国“多党合作”的鲜明特点。

1954年宪法确立的宪政体制和今天是一样的。

| 这部宪法在中国实施持续的效果并没有持续很久，因为1956、1958大跃进、1968文革。可以说1956以后，中国社会走进一个很不稳定的状态。而**宪法上层建筑的发挥有赖于社会政治、经济、文化状况**。

(3) 1975年与1978年宪法，在特殊时期通过，带有明显的局限性

这两部宪法对于1954年宪法有大修改，都是建立在1954年宪法的基础上，因为中国的社会根本制度没有变化。所以这两部宪法不是“制定”，只是“修改”。

但是这两部宪法带有明显局限性，内容上带有明显文革时期的烙印。

(4) 1982年宪法12月14日——中国现行宪法

对于先前宪法的大修改（非“制定”），依旧承续1954年宪法的宪政体制。

至今天，1982年的宪法经历了五次修改——88、93、99、04、18，其中修改最多的就是中国的经济体制。1978年改革开放，开始搞市场经济，允许私营经济存在。但是这些试验性的东西不能立刻写入宪法，写入宪法就是稳定固定的。所以在1982年宪法我们还是计划经济，但是现实生活中已经有了市场经济。所以在1988年加入了部分市场经济，1993年市场经济作为补充部分，1999年说市场经济是重要组成部分，2004年私有财产入宪。

专题一 宪法是什么

(章节：第一章第一节)

一、宪法含义

(一) 宪法一词的来源

这两个字在中国古代、西方古代都有，并不是资产阶级革命后才出现的。而近代宪法一定是产生在资产阶级革命的基础之上，其使命是：控制国家权力、保障公民权力。所以古代近代宪法差异很大，古代是为了王权，近代是为了人民。

(二) 有关宪法的观点

当代西方学者的观点

宪法规定政府的主要机构的组成、权力和运作方式的规则以及政府机构与公民之间关系的一般原则的文件

宪法是一个国家的根本的和系统的法律，它的作用是确立政府机构和国家统治权的范围，保障权利和自由。

马列宪法的观点 (中国对于宪法定义的特点-领导者)

马克思：不列颠宪法实际是统治者资产阶级社会的阶级之间妥协。

列宁：什么是宪法，宪法就是一张写着人权利的纸。

斯大林：宪法是根本法，而且仅仅是根本法。

毛泽东：宪法就是一个总章程，治国安邦的总章程，是根本大法。

中国老一辈学者的观点 (学者将定义学术化)

宪法是国家的根本大法。

宪法是民主制度的法律化。

宪法是阶级力量对比关系的体现。

我国学者传统的代表性观点：

宪法是集中表现统治阶级意志的国家根本法。

韩大元：什么是宪法，这个命题也许是没有答案的。

童之伟：宪法是分配法权并且规范其运用行为的根本法。

胡锦涛：宪法的精神犹如禅一般。

林来梵：宪法就是做答式解释。

刘茂云：宪法就是组织共同体的规则。

林峰：宪法是一个章程。

——《山东》社会科学2006年第8期

【讨论】对宪法这些概念解读时候的立场 (客观、理性、学术的立场)

如果一个问题涉及事物本体同时又是一个终极命题的话，见解往往不可能达成一致，因此，我们所需要的可能是在不同语境中去解释含义以及从不同层次去结构事物的整体。所以在本次专题设计中，从四个角度解答“宪法是什么”的问题。

那么每一个人都可以描述宪法，那现在的问题是这种描述有没有底线？——对于各种现象解读的时候，是要有底线的。

(1) (对宪法的理解、解读是可以多角度的) 宪法是根据一定的历史和环境而制定的具有复杂构造的法，因此，要阐明宪法除了法规范意义上的考察外，还有必要进行历史、政治学、社会学等的考察。

(2) (基本底线) 不易混淆宪法对象的政治性与研究对象所采用方法的政治性。不应以主观的政治歪曲宪法的规范性。

→ 对宪法解读的基本原则是尽量解读是一致的。

(3) (高阶底线) 必须认识宪法内在的或寓于宪法中的普遍性的法理念和政治理念。

→ 控权 保权

——芦部信喜

执政党怎么让自己的意识上升为国家意志——立法。

二、宪法特征

即描述宪法的样子。

(一) 宪法形式特征：宪法是根本法 ★★★

1. 内容上：宪法规定的是国家生活中最根本、最重要的问题。

宪法第1、2点就在设计中华人民共和国是什么样子的。

2. 效力上：宪法具有最高法律效力。★★

(1) 宪法是其他法律的立法依据

(2) 宪法和普通法律相比，具有最高的效力。一切法律规范的制定都必须以宪法为依据，其内容和精神不得与宪法的原则和规定相抵触、相违背，否则会因违宪而无效。

(3) 宪法是一切国家机关、政党、社会团体和公民的最高活动准则。

3. 程序上：宪法的制定与修改程序比普通法律更为严格、复杂。（只针对成文宪法国家）

* 任何一部法律（包括宪法修正案）修改的程序：

提案：宪法需全国人大常委会/五分之一以上（600以上）的人大代表联名提案；根据我国立法法，其他法提案主体有九个（一个普通法律修改30人大代表联名提案）。

审议：

表决：宪法修正案全体（不出席视为弃权）代表2/3以上通过；普通法律过半数

公布：宪法由全国人大公告；普通法律是由国家主席公告（国家主席公告是宪法规定的职权）

（二）宪法的实质特征——控权保权

1. 保障公民权利
2. 规范和控制国家权力

三、宪法分类

（一）宪法的形式（传统）分类✓

1. 成文宪法与不成文宪法✓

是指有没有将宪法集中规定在一个文本上（不是有没有文字）

2. 刚性宪法与柔性宪法

根据宪法制定修改程序，更严格的是刚性宪法。成文宪法是刚性宪法，不成文宪法是柔性宪法。

3. 钦定宪法、民定宪法与协定宪法

历史上才有钦定或者协定宪法，目前都是民定宪法。

中日历史上有钦定宪法，法国历史上有过协定宪法。

四、宪法渊源

法学角度说渊源：法律规范的表现形式，法律载体。

1. 世界范围内✓

宪法典、宪法修正案、宪法性法律、宪法惯例、宪法判例、宪法解释、~~国际条约、其他渊源。~~

2. 中国范围内

宪法典、宪法修正案、宪法解释

【争议】宪法性文件

在中国这样的成文宪法语境下，不应该有宪法性法律，不然会引起逻辑上的混乱。比如如果有宪法性法律文件，那《立法法》、《选举法》等都是公认的宪法性法律，而宪法性法律又是中国渊源的话，那么这些法律是不是宪法？——不是，这里是说承载着宪法的载体，具有宪法效力的。| 英国的宪法性文件，是从国会立法中挑出了规定宪法内容的法律。正是因为有了宪法性文件的概念，英国区分了宪法和法律，解决了“没有宪法的国家”的称呼问题。

【争议】宪法惯例

宪法渊源越久的国家，越会有惯例。但是中国有没有宪法惯例是有争议的。（姚妈）有学者找到了，并且该观点是可以接受的：“公布”宪法的制

定和修正都是由全国人大公告，但是一直没有写到宪法中去——从1954年即有此习惯。

【争议】有没有宪法解释的实践

五、宪法结构

序言+正文（总纲，公民的基本权利和义务，国家机构，国旗、国歌、国徽、首都）

宪法修正案和宪法地位一样

华东政法大学法律学院 24010102016

专题二 宪法的基本原则

——各国宪法中普遍承认的原则

【整体学习方法】

内涵（前提）+起源与发展+原则在中国宪法中是如何体现的

一、人民主权原则

（一）人民主权理论

1. 人民

· 人民与公民（中国）：①人民是政治概念，与敌人对应；公民是法律概念，与外国人相对②二者范围上：不是包含关系。人民的概念是历史相对的概念（具有立场的相对性+不同历史阶段界定不同）；公民的概念是确定的概念——有中国籍。

· 国民=公民：只是表述不同

2. 主权

· 是一种管辖权：①对外：自己管理自己，其他国家不能干涉。②对内：统治权，即政权（power）。可以描述为立法、行政、司法（、监察）权。

3. 人民主权理论评述：其含义为主权属于人民，在人民手中。

评价：①优点-历史的进步性：启蒙运动中的人民主权是用来推翻封建地主阶级的重要思想武器，最终引导着资产阶级革命获得成功。这个历史角度上，人民主权取得了转折性的进步。②缺点-直接民主不可能实现「全民公投」，间接民主在现实中不一定能够获得落实；人民主权先天性无法完全实现。（姚）但是还需要，因为需要给政府划定底线。

（二）人民主权原则在宪法中的确立与发展

· 起源：法国《人权宣言》（1789年近代宪法的先驱之一）第3条确立的“主权在民”。

· 英法美先驱国家编写宪法时均编入人民主权原则。

（三）中国宪法中的人民主权原则

《宪法》第2条 中华人民共和国的一切权力属于人民。

二、基本人权原则

“永远把人类当做一种目的而决不仅仅是一种手段来对待”。——康德

· （英）米尔恩：《人的权利与人的多样性——人权哲学》，谓：基本人权应该找的是低限人权理论（最低限度道德权利的人权）。

低限人权实现的方式有二：①语境解释原则：要站在不同的角度分析②消除差距原则：不论站在哪个角度，无论如何是要消除人权之间的差距，即一定要向着人本身去发展。

（一）人权理论

1. 人权理论的起源

人权的概念很新，不是有了人就有了人权，而是预示着社会的重大变化。所以天赋人权是在资产阶级启蒙运动的背景下提出。

2. 人权理论的理解

人权是每个人享有的或应该享有的权利。

· “享有的”：即为得到的。怎么判断呢？——是宪法和法律中已经规定的权利，但是不等于已经实现，具体实现要看国家、社会等的情况。

· “应该享有的”：预示人权的概念是发展变化的。即没有在宪法和法律中规定，但是认为应该努力推动宪法法律修改加入的权利。

eg. 【户籍制度vs迁徙自由】

3. 低限人权理论

（二）基本人权原则在宪法中的确立与发展

· 英美法一开始就确立的人权原则

（三）中国宪法中的基本人权原则

· 2004年重大跨越：加入“尊重和保障人权”。

《宪法》第33条至第50条基本权利

【思考】人权入宪问题

三、法治原则

未经正当法律程序不得剥夺任何人的生命、自由和财产。——1791年美国宪法第5条修正案

→ 法律程序：法律规定的，但是不是所有法律规定的都正当。

→ 正当：符合宪法的精神和内容；自然法学角度；…

（一）法治含义

1. 法治的内涵：

· 亚里士多德：已成立的法律获得普遍的服从，而大家服从的法律又应该本身是制定得良好的法律。

→ 服从

→ 服从的是良法

→ 对于恶法要不要服从？（即恶法是不是法）——特殊时期希特勒纽伦堡审判结论“恶法非法”。（姚）但是那是特殊时期，非特殊时期能不能适用？恶又由谁来判断？

答：（姚妈）在非特殊时期+不涉及人类根本性问题时，面对法律首先是要“服从”，确立法律在国家中的权威。当个人认为法律不符合实践经验时，可以以各种方式提出建议。

2. 法治的理解

- 法治的执法不可能脱离人的治理和理解。
- 所以区分法治人治的方式是：当法律和人的权威与意志相冲突时，选法律就是法治；选领导人就是人治（并非绝对，而是保留领导人色彩）。

（二）法治原则在宪法中的确立与发展

- 英美法

（三）中国宪法中的法治原则

- 1999年修宪重要节点：将依法治国写入宪法，要建设社会主义法治国家。

《宪法》第5条

四、权力制约原则

凡权利无保障（宪法的终极目标）和分权（手段）未确立的社会，就没有宪法。——人权宣言第十六条

（一）权利制约理论

- 权利制约&保权中保权是核心，因为主权在民。但是是人民代表获得权力管理人民，此时需要进行权力制约以保证其为人民服务。——所以此时有个前提是“权力的来源是恶的”。
- “一切有权力的人都容易滥用权力，这是万古不变的一条经验，有权力的人们使用权力一直到界限的地方才罢休。”
- “如果人是天使，就不需要政府了；如果天使统治政府，那就不需要对政府有任何外在或内在的控制了”。

1. 洛克（近代分权学说倡导者）：立法权、行政权、对外权

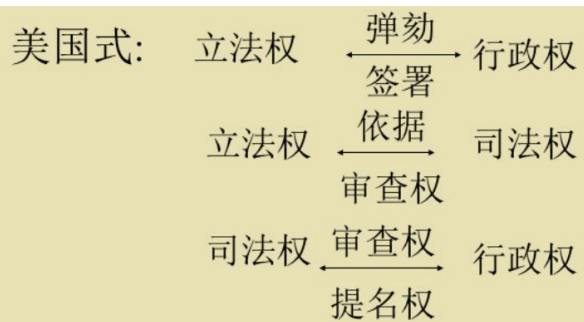
2. 孟德斯鸠（分权集大成者）：立法权、行政权、司法权

3. 美国联邦党人

（二）权利制约在宪法中的确立与发展

1. 文本意义上的确立

- (1) 1787年，美国宪法；
- (2) 1789年，法国《人权宣言》；
- (3) 1791年，法国宪法



英国式： 议会内阁制

法国式： 半总统半议会制

2. 权力制约的模式：

（三）权利制约机制在我国

《宪法》第3条 中华人民共和国的国家机构实行民主集中制

民主集中制运作机制——“品”字型结构，顶部为立法权。现已变成下三“口”，因为多了一个监察权。

专题三 宪法的运行

一、宪法的制定（制宪权）

1. 制宪权 宪法 立法权

我国中央立法权掌握在全国人大及常委会中，是宪法明文规定的。

· 立法权——派生性/本源性的权力

第五十八条 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。

第六十二条 全国人民代表大会行使下列职权：（一）修改宪法；（二）监督宪法的实施；（三）制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律；

（四）选举中华人民共和国主席、副主席；（五）根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选；（六）选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；（七）选举国家监察委员会主任；（八）选举最高人民法院院长；（九）选举最高人民检察院检察长；（十）审查和批准国民经济和社会发展规划和计划执行情况的报告；（十一）审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告；（十二）改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定；（十三）批准省、自治区和直辖市的建置；（十四）决定特别行政区的设立及其制度；（十五）决定战争和和平的问题；（十六）应当由最高国家权力机关行使的其他职权。

2. 制宪权主体——本源性/理论性的权力

（1）制宪权不可能在宪法中规定，因为是先有制宪权再有宪法「你不能规定」。

（2）制宪权的主体是人民。该观点背后的理论基础：人民主权理论——是现代资产阶级革命启蒙运动才有的。

【讨论】但是从实践上来看，制定宪法过程中如何落实制宪权主体是人民的？

『中国』

宪法起草小组 ⇌ 中央政治局



宪法起草委员会



第一届全国人大第一次会议

—宪法生效，落实制宪权主体是人民（人大代表是人民选出来的）

『美国』

制宪会议 (1787-1789)

—宪法生效在1788年，按照生效的宪法选举美国总统，1787-1788年交给13个州议会3/4批准（第九个批准）时候生效（议员是人民选出来的）

*制宪会议时候不算，因为制宪会议代表不是人民选出来的

二、宪法的修改（修宪权）

1. 为什么要修宪

宪法是上层建筑，由经济基础决定。所以当经济、文化等等变化时就一定要修宪。

2. 我国修宪的主体、程序及修改情况★

(1) 主体：全国人大的独特权利。

第六十二条 全国人民代表大会行使下列职权：（一）修改宪法；…

(2) 程序

第六十四条 宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

(3) 修改情况

75、78、82—宪法修改，但属于大修改，都是对于54宪法的。

对于82年宪法有五次修改：88、93、99、04、18（要熟悉，每次修改中突出的亮点，对我们国家发展有转折性意义的——比如人权写入宪法是04年、经济制度贯彻了前四次修改）

三、宪法的解释（释宪权）

1. 何谓释宪？

对于宪法的内涵和外延进行解读，角度方法多种多样。

2. 我国释宪问题

(1) 主体：全国人大常委会

第六十七条 全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）解释宪法，监督宪法的实施；（二）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；…

【争议】全国人大能否解释宪法——能，但为附带性/派生性解释

此处的宪法解释，不同于第67条。第67条是一个独立的职权，只要想解释即可解释没有附带条件。而全国人大的解释一定包含在监督中。

四、宪法的实施（违宪审查权）

——宪法运行中极其重要的东西，并且体现宪法权威性中重要的威慑力

1. 宪法实施的内涵：将宪法的内容动起来

2. 我国宪法的实施路径

(1) 宪法遵守：（消极的用）

即遵守宪法，人人有责。但是如果靠着人人遵守宪法的角度落实宪法实施，是非常理想化的。

(2) 宪法适用：（积极的用）

即有没有权用「直接用」宪法去解决宪法问题。这才是非常实际的。

这是一个power的问题，要到宪法中去找：

i 全国人大及其常委会是最最主要的主体——①根据宪法制定法律②人大宪法修改权，人大常委会宪法解释权③宪法监督权。

ii 国务院

第八十九条 国务院行使下列职权：（一）根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令；…

国务院是行政机关，属于权力执行机关（也被称为执法机关）。其为全国人大及其常委会的权力执行机关/执法机关，所以一定执的是全国人大及其常委会的法。

所以必须优先执行全国人大及其常委会的法规。只有在没有这类法规的情况下，才要去根据宪法制定行政法规。「只要法律制定的约完备，国务院就越来越不会依照宪法制定行政法规」

(3) iii 我国法院能适用宪法吗？

丨【齐玉苓诉陈晓琪案(2001年)】

经研究，我们认为，根据本案事实，陈晓琪等以侵犯姓名权的手段，侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育权的基本权利，并造成了具体的损害后果，应承担相应的民事责任。——最高法院法释[2001]25号

违宪责任是一种政治责任，不是简单用钱解决的问题，所以此处为“民事责任”。

最高人民法院于2008年12月8日通过了《关于废止2007年底以前发布的有关司法解释(第七批)的决定》，其中包括《最高人民法院关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》，其理由是“已停止适用”

最高人民法院关于印发《人民法院民事裁判文书制作规范》《民事诉讼文书样式》的通知法(2016)221号(七)裁判依据

4.裁判文书不得引用宪法和各级人民法院关于审判工作的指导性文件、会议纪要、各审判业务庭的答复意见以及人民法院与有关部门联合下发的文件作为裁判依据，但其体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述。（裁判依据里面不能引用宪法）

丨【讨论】 最高院说的算？——应该是宪法说的算。

第一百三十一条 人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

→“法律”是否包含宪法？（姚岳斌：《我国宪法第126条“法律”外延的界定》，载《政治与法律》2010年第9期）不包括。各国对比来看，一个国家机关有没有职权使用宪法，都会将宪法独立写出——这是世界通用的立宪技术，大家特意的将“宪法”区别于“法律”。

（我国采取的宪法解释是立法机关解释，按照宪法规定只能依照法律行使。）

所以宪法不能成为我国法院的判决依据。|但是宪法可以作为判决理由「论证公民的权利应该得到保护」，推动宪法的发展。

3. 中国的违宪审查制度内容与实践★ ★ ★（大于15'）（违宪审查≈监督宪法的实施—进一步落实宪法的威慑力）

A. 【制度本身】宪法及法律依据（背）：

a. 主体：全国人大和全国人大常委会

b. 对象：全国人大监督全国人大常委会（12）；全国人大常委会监督国务院以及省级权力机关（人大、人大常委会）（7、8）

【区别】人大工作监督：还有国务院、最高院、最高检

（1）宪法第62条第2项：监督宪法的实施（宪法上明文规定的power）

第12项：改变或撤销全国人大常委会不适当的决定。

（2）宪法第67条第1项：解释宪法，监督宪法的实施

第7、8项：撤销国务院以及省级权力机关制定的同宪法相抵触的法规、决定和命令。

c. 监督的程序（宪法中无规定，规定于立法法第五章）（对应书本第五章第五节）

（3）立法法的细化（第五章：适用与备案审查）

【审查流程的启动】

➤ 第一百一十一条（启动方式1：提出审查的要求） 第一百一十条 国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规（国务院制定的）、地方性法规（地方人大制定的）、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求，由全国人民代表大会有关的专门委员会和常务委员会工作机构进行审查、提出意见。

（启动方式2：提出审查的建议）前款规定以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民（只有1个公民都可以）认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人民代表大会常务委员会

员会书面提出进行审查的建议，由常务委员会工作机构进行审查；必要时，送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

➤ 第一百一十一条（启动方式3：主动审查）（已成为日常工作）全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构可以对报送备案的行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

国务院备案审查工作机构可以对报送备案的地方性法规、自治条例和单行条例，部门规章和省、自治区、直辖市的人民政府制定的规章进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

【审查的过程】

➤ 第一百一十二条 全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构在审查中认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向制定机关提出书面审查意见；也可以由宪法和法律委员会与有关的专门委员会、常务委员会工作机构召开联合审查会议，要求制定机关到会说明情况，再（全国人大及常委会）向制定机关提出书面审查意见。制定机关应当在两个月内研究提出是否修改或者废止的意见，并向全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会或者常务委员会工作机构反馈。

【审查的结论】

| 全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会、常务委员会工作机构根据前款规定，向制定机关提出审查意见，制定机关按照所提意见对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例进行修改或者废止的，审查终止。

——整个流程并不公开化

| 全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会、常务委员会工作机构经审查认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题需要修改或者废止，而制定机关不予修改或者废止的，应当向委员长会议提出予以撤销的议案、建议，由委员长会议决定提请常务委员会会议审议决定。

——到了“常委会审议”则公开化。因为此时的方式是开会投票，少数服从多数，审议决定需要公告否则不生效。

▲（姚妈）：此时的审查制度设计漏洞：（1）法律不纳入审查范围。但是根据宪法规定，法律需要被审查。（2）全国人大无法被审查（故此处的制度设计认为“全国人大天然不会犯错”）

（4）2018年第五修正案将第70条“法律委员会”修改为“宪法和法律委员会”，统一审议

学习法国宪法委员会，在每一次法律推行之前，就要把宪法的关。

(5) 2004年，全国人大常委会法制工作委员会下设了**法规审查备案室**
从2022年，法制委员会工作报告开始出现了宪法审查的工作问题。

(6) 监督法的补充

描绘制度的逻辑结构（如违宪审查）：①主体（谁拥有违宪审查权）②对象（审查谁）③程序（审查程序）④结论（如果违宪怎么办）

B. 【实践】

【孙志刚案（2003）】

第三十七条 中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

【延伸】（背条款）绝对法律保留事项——包含人身自由的限制问题

涉及公民人身自由的问题，只能由全国人大及其常委会制定。

《立法法》

第十一条 下列事项只能制定法律：

- （一）国家主权的事项；
- （二）各级人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；
- （三）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；
- （四）犯罪和刑罚；
- （五）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；
- （六）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；
- （七）对非国有财产的征收、征用；
- （八）民事基本制度；
- （九）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；
- （十）诉讼制度和仲裁基本制度；
- （十一）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

第十二条 本法第十一条规定的事项尚未制定法律的，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，**但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外。**

所以当时国务院制定的《收容遣送办法》违宪，应当由全国人大常委会撤销。孙志刚案在实质上启动了中国的违宪审查制度，只是我们看不到（只是看到外表上国务院自我纠正），所以我们可以合理的怀疑猜测，这个案件如此解决一定受到了全国人大的压力。

【劳动教养规定的废止】

不属于标准化违宪审查，废除理由是“现在不再需要”。

【黄海波收容教育案与雷洋案】——强制收容教育制度的废止

所针对对象特殊：卖淫嫖娼者。

全国政协委员朱征夫建议对卖淫嫖娼强制收教进行合宪性审查。

不属于标准化违宪审查，废除理由是“现在不再需要”。

【对违法犯罪人员亲属的“连坐”制度考察】

于2023年法制委员会工作报告中提出。

四、宪法的基础理论思考题

（书本第一、五章）（笔记专题一-三）

1. 宪法的涵义与特征
2. 宪法基本原则的涵义以及在我国宪法中的表现形式与内容
3. 宪法渊源与分类
4. 中西方宪法历史的概况及宪法制定情况
5. 我国宪法制定、修改与解释的主体、方式与程序等
6. 我国宪法保障的历史与现实
7. 我国宪法保障的历史与现实
8. 我国违宪审查模式内容与评析

专题四 宪法权利篇

· 宪法是用来规定公民权利的。而有关公民的义务、行为由普通法律调整，不由宪法调整。宪法中规定义务属于社会主义国家特色，因为我国制宪时考虑人民当家作主，所以需要有义务，如劳动作为义务。

教学目标：通过学习，正确理解人权、公民权、公民基本权利等基本含义，把握公民在国家生活中的地位（是什么）。联系实际，结合宪法理解各项基本权利以及理性分析它们的保障与落实状况（大量案例分析-分析存在的不足）。

教学内容：权利的归类可以按照以下：

一、公民基本权利与义务概述（理论）

（第二章-第一节·部分内容自学）

1. 公民与国籍

· 什么是公民：具有某个国家国籍的自然人。

→ “自然人”：说明不是法律拟制上的。

→ 国籍：法律上给予的身份。国籍的取得不同国家不一样。

原始国籍的取得方式是：因一个自然人的出生而取得。

→ 因出生而取得（原始国籍）取得标准：①血统主义：看父亲or母亲的国籍；②出生地主义：出生地

——中国国籍采取的方式是两个标准都用。但是禁止多重国籍。国籍的选择在自然人未成年之前由父母选择，在成年之后自己可以重新选择一次。

美国也是均采；英国是只采用血统主义。

继有国籍的取得方式是：因为申请而加入某个国籍

2. 公民、人民与国民

* 国民和公民的概念没有任何本质区别。出现这两个概念的原因是习惯用法不一样，更多国家的习惯用法是“公民”，但是像法国特别喜欢用“国民”。

· 公民和人民的区别（基本原则的学习通）：（1）人民是政治概念，对应的概念是敌人；公民是法律概念，对应的概念是外国人（没有中国国籍的自然人）。（2）范围不一，公民和人民的概念是交叉关系：但凡属于宪法序言中“爱国统一战线”的人都是中国人民。（* 爱国者一定不是中国公民）（3）公民是个体概念，人民是集体概念

3. 人权、权利与基本权利

· 人权：很新的概念，因为过去不是所有人都是“人”——必须是成年+男性。

i 关于人权问题的重要文献

- (1) 1776年美国《独立宣言》
- (2) 1789年法国《人权及公民权宣言》
- (3) 国际人权宪章

1948年《世界人权宣言》

1966年联合国通过《公民权利和政治权利国际公约》 1966年联合国通过《经济、社会、文化权利国际公约》

(4) 1977年联合国通过《关于人权新概念决议案》，人权不仅包括个人权利，还包括民族和人民的权利和基本自由。

(5) 1979年联合国通过《决议》强调国家主权、民族自决权、发展权和基本人权。

ii 我国政府对人权的态度

- (1) 1991年发布《中国的人权状况》这一白皮书
- (2) 1997年，签署《经济、社会和文化权利国际公约》
- (3) 1998年，签署《公民权利和政治权利国际公约》
- (4) 2001年，全国人大常委会批准《经济、社会和文化权利国际公约》
- (5) 2004年，宪法修正，增加“国家尊重和保障人权”

· 权利：一般认为权利指的是由法律规范所认可的，表现为法律关系中一方对另一方享有的可以要求对方为一定行为或不为一定行为的一种资格

- (1) 权利存在于双方主体之间的法律关系中呢
- (2) 权利是有先有法律规范所认可的
- (3) 权利是一种资格可能性，实现要结合主观和客观

· 基本权利：一般来说，基本权利=宪法权利。（其他内容自学）

- 基本权利（宪法权利）的范围——除宪法明确列举外，还有么？还有哪些？

(1) 背景：（天赋人权）法律将公民的权利写入，是法律保障这些权利，不是法律赋予的。公民的权利是天赋的。

宪法列举的一定是基本权利，没有列举出来的不一定。

“本宪法对某些权利的列举，不得被解释为否定或忽视人民保留的其他权利。”——美国宪法第九修正案

(2) 此外基本权利在哪里？——宪法解释

“不经正当法律程序，不得剥夺任何人的生命、自由或财产，对于在其管辖下的任何人亦不得拒绝给予平等的保护。”——美国宪法第十四修正案

Eg: 美国将隐私权写进宪法，中国的隐私权只是民法权利上的，没有办法抵御国家的隐私侵害。

4. 公民基本义务（课后看一下从宪法第52条开始）

二、公民权利与义务的平等性

学习步骤：权利在宪法中的规定——围绕文本怎么理解——不同国家之前权利是怎么落实的、侵权怎么救济

（一）公民平等的宪法规定内容

（不是主观上的平等，而是法律意义上的平等）

“平等在每一天都会给每一个人带来许多小小的快乐。平等的美丽每一个时刻都能感受得到，每一个人都能够获得。最为高贵的人能感受它们，最为普通的人也以它们为乐”——托克维尔

· 各国宪法条文中关于平等的表述

1. 平等保护（美）
2. 法律面前一律平等（德）
3. 法律上一律平等（日）

· 我国宪法中规定的平等内容★★★（简答题）

抽象的规定（33）

具体的规定（34、36、48等）

1. 中华人民共和国在法律面前一律平等（第33条）
2. 民族平等（序言与第4条）
3. 选举权平等（第34条）
4. 宗教信仰平等（第36条）
5. 性别平等（第48条）

（二）“法律面前一律平等”的理解（要看p82判断程序）

· “法律面前”一律平等的含义★（背）

1. 所有公民都平等地享有宪法和法律规定的权利，
2. 所有公民都平等地履行宪法和法律规定的义务
3. 国家行政机关、司法机关在使用法律时，对所有公民的合法权益都应平等地予以保护，对所有公民的违法或犯罪行为，一律平等地依法追究法律责任。
4. 任何组织或个人都不得有超过宪法和法律的特权。

· 平等的理解

1. 法律平等与事实平等

两个小朋友同年同月同城市生，一个小朋友出生在富裕家庭，一个出生在工薪家庭。富裕家庭能读最好的幼儿园，工薪家庭孩子选择就近的普通公立幼儿园。进而后面的人生轨迹都有所分别。——这二者在法律上是平等的。

· 法律平等

· ~~事实平等~~：事实上，这个社会就是不平等的，而且某种角度上是无法更改的。（《私有制》恩格斯）自从国家和私有财产产生，就会产生事实上大家有多有少的问题。

首先，必须树立的理念是：我们说的是法律平等，不是事实平等。如果被事实平等牵着走，就会影响到个人人生观、世界观——一个人生在某一个环境是注定的，如果想要改变环境就要改变自己。

其次，要正视事实，因为事实事实不平等会影响个人的机会，但是此时是国家、政府应该关注到的事。如贫富差距/老无所养是客观事实，政府需要做的就是想办法缩小贫富差距 如交个人所得税/发展社会保障制度。（平等≠平均）

2. 程序平等与实体平等

【华人洗衣店案】

（立法）1880年，旧金山市制订一项法令，规定：“如从本法令通过之日起，任何人未经管理局事先同意，即在旧金山市县内建立、维持或从事洗衣业，那都是构成违法，在砖瓦房内的洗衣店除外。”违者或处罚款或监禁。

（立法背景：法律出台之前，在美国旧金山中，开洗衣店统一不用许可。但是之所以1880年出台这样的法律，是因为前几年每年都会发生火灾，通过数据发现绝大多数火灾发生在洗衣店内，而且只发生在木头房子的洗衣店内。之所以容易发生，是因为洗衣机和烘干机是电器，而环境潮湿，容易短路引起火灾）

（执法）当时旧金山市内320家中240家归华人所有，310家洗衣店和当时市内90%以上房屋是木头结构。原告吴氏等华人从事洗衣业多年，他们申请延长执照的请求被拒绝，又因继续从事洗衣业而处罚款，因没有交款而判监禁。

（执法结果：木头房子华人去申请几乎都被拒绝了，非华人去申请几乎都被通过了）

（司法）吴氏请求加州最高法院推翻市管理局的决定，加州最高法院认为“市管理局官员是权衡事实的法官”因而维持市管理局决定上诉至联邦最高法院，加州法院的决定被推翻。

（1）法律规定本身是行政许可问题，区分了木头和砖瓦的房子，是为了对洗衣店进行事先审查，进而看是否合规。就这个法律本身而言，不存在对某一类人的歧视，程序上是平等的。

（2）执法程序中，华人都被拒绝，系旧金山管理局存在歧视。

- 程序平等：表面上没问题
- 实体平等：实体不是事实，事实是客观表面上的。实体是执法结果，实体平等是在追求正义。“法律本身可能在表面上是公正无偏，但如果它被公权力不公正地加以运用与事实，因而在实际上非法歧视了处境类似的个人权利，那么宪法仍然禁止法律对平等正义的剥夺”。——美国宪法第十四修正案的“正当程序”与“平等保护” 马斯修法官在法院意见的指出。

3. 机会平等与结果平等（平等与平均）

- 机会平等
- 结果平等=平均：不是客观事实的描述，是行为选择中大家得到的最终结果。
「“实体”是执法结果，概念有所交叉」

4. 平等与合理差别（平等的分析过程——证明合理）

平等不意味着没有差别，关键的是差别要合理。

- (1) 几乎所有的法律都含有归类（classification）：对不同类别的公民规定不同的权利或义务。
- (2) 并非所有归类都违反平等原则，只有任意或不合理的归类才构成“歧视”（discrimination）。
- (3) ★★★归类必须合理而非任意：必须具有正当目的，且目的和归类手段之间存在合理的联系。（平等的分析核心——先考虑目的的正当性：为了公共利益。再考虑手段的正当性：手段和目的之间是不是必然的、重要的，有没有更好的手段）

→ 怎么判断合理？

区分三层：在不同领域中，严格的合理、中等的合理、简单的合理

→ 流程★★★：

立法依据

此立法依据的立法目的，正当性（公共利益）

为实现立法目的所采用的手段是什么

手段的设定与立法目的之间的关联性如何★——强关联、弱关联、中等关联

手段是强制还是选择？是权利还是义务？

【退休性别歧视案】

2005年，周女士，系原中国建设银行平顶山市分行出纳科副科长。今年55岁的周女士认为自己身体很好，可以胜任工作，没有到必须退休的地步。但平顶山市分行认为，依照《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》，周女士已达到55岁的法定退休年龄，必须退休。于是，周女士向平顶山劳动争议仲裁委员会提出仲裁请求。

法院审理认为，被告建行平顶山分行的决定符合现行国家政策和法规，并无不当。周女士认为被告为其办理退休手续的决定违背了宪法关于男女平等的原则，要求予以撤销的理由无法律依据，法院不予支持。

全民所有制企业、事业单位和党政机关、群众团体的工人，符合下列条件之一的，应该退休。

(一) 男年满六十周岁，女年满五十周岁，连续工龄满十年的。

(二) 从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作，男年满五十五周岁、女年满四十五周岁，连续工龄满十年的。

本项规定也适用于工作条件与工人相同的基层干部。

(三) 男年满五十周岁，女年满四十五周岁，连续工龄满十年，由医院证明，并经劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的。

(四) 因工致残，由医院证明，并经劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的。

(1) “可以”≠“必须”

(2) 男女60、55周岁的划分是否平等：归类目的是从身体机能的角度出发，具有正当性。手段上是？？

宪法问题应该找全国人大常委会。

国务院在退休标准中设立了“性别”、“年龄”两个标准。

1. 男女退休年龄设定的立法依据是什么（国务院是否有权讨论）

有《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》、《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》。两者性质上是行政法规，而且这两个行政法规涉及到公民的劳动权，国务院的行政权力能够限制宪法上公民的劳动权。

- 劳动权的限制是不是法律保留？不是。

2. 此立法依据的立法目的是什么，正当性（公共利益）

目的是“…妥善安置…，推动社会主义建设…”。最重要的目的是国家发展，是正当的。

(一) 年龄

3. 为实现立法目的所采用的手段是什么

划分年龄。

4. 退休条件的设定与立法目的之间的关联性如何（从各个你认识到的角度来论证）

年龄和退休之间的关联性在：从目的出发，要让工作效率低下的人退休。判断工作效率低下：老年人到年龄了机能会降低。论证：各个国家均以年龄为标准退休；光以工作效率低为标准是不可操作的，但是以年龄为标注是可操作的；…

而对于退休问题，只需要考察中关联性。不需要年龄和工作效率严丝合缝，所以不需要考虑普遍性因素，而不是偶然性因素。

(二) 性别

3. 为实现立法目的所采用的手段是什么

划分性别。

4. 退休条件的设定与立法目的之间的关联性如何

1978年，设置退休年龄差的本意是照顾女性（退休本质是社会福利制度，所以设置女性先退休，就是让女性先享有社会福利——基于女性在社会责任中的配置不同，即女性在家庭中的责任分配过多，且女性系弱势群体）；客观上劳动密集型，女性身体机能上，比男性更弱。

今天，男女性别和劳动效率的关联性到底如何？→今天的中国还需要照顾女性吗？→今天的中国还需不需要以特殊照顾的形式保护女性？

5. 退休是强制还是选择？是权利还是义务？

强制的退休制度对公民来说是限制剥夺公民的劳动权，而在限制公民劳动权面前区分男女并不公平。

所以也许可以改革成：女性有选择权，可以选择到和男性一样退休。

【比较法】波兰

启示：差别对待所保护的重要利益与不平等对待所侵犯的利益保持适当的比例

问题：这里“平等”的界定？

(4) “平等”的效果：处境类似的人获得类似待遇。

● 平等章节启示：大家要克服或者避免以前对平等的感受。

三、公民公共参与权利的保护

第三十四条 【选举权和被选举权】 中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

第三十五条 【政治自由】 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

第四十一条 【监督权与请求权】 中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

(一) 政治自由

I 政治自由的宪法规定

第三十五条 【政治自由】 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

“国会不得制定有关下列事项的法律，即确立一种宗教或者禁止信仰自由；限制言论自由或出版自由；或限制人民和平集会的权利以及向政府请愿的权利。”——美国宪法第一条修正案

· 注：出版自由不属于文化自由，而是政治自由。

· 注：以上自由最重要的就是「言论自由」（表达观点和思想的自由——既然是政治自由，那么就是表达的对于政府国家等等的观点和思想的自由），其他均为言论自由的表现形式。

II （核心）言论自由

1. 言论自由的含义（见教材）

2. 言论自由的宪法保护与界限

言论自由的界限要根据对象和内容有所区别

根据言论自由的对象和内容的不同，保护程度可分为：

（1）明显和即刻的危险原则

针对政府和国家工作人员的批评言论。

言论自由的权利范围越大越好——本质：一切权力属于人民。

【申克诉美国案（1919年）】（起源）

本案发生于1919年。申克是美国社会党总书记，在第一次世界大战期间，申克与其友人共同向应征参军男子散发反对征兵的传单，不仅抨击征兵为违宪虐政，而且还煽动应召男子维护他们的权利，抵制征召。这种言论被政府当局认为企图妨害国会募集军队的权利，因而对其提起控诉。联邦区法院判决申克违反1917年的反间谍法，构成犯罪。

反间谍法是美国国会继1798年的危害治安法(The Sedition Act 1798)后制定的第二个管制言论的法律，经1918年修正，规定了12项对言论的管制情况，其中第2项和第3项涉及到征召兵员和煽动反叛的言论管制。申克辩称反间谍法违背了宪法第1条修正案对公民言论自由的保护，不应适用本案，因而上诉到最高法院。

联邦法院在审理本案时，则全体一致认为申克有罪，支持原判决。首席大法官霍姆斯(Justice Holmes)在判词中首次提出衡量公民言论自由的“明显而即刻危险”标准。他这样写道：

“平时，被告在其传单中所讲的内容是在宪法权利的允许范围内，但是每一个行为的性质依其环境情势而定。最严格的对言论自由的保护也并不保护一个人在剧场不真地呼喊失火并引起惊慌。一切与言论自由有关的诉讼案件，其问题是要判断使用的话语是否发生这样的环境情势中并具有这样的性质，以致造成明显而即刻的危险，而造成国会有权防止的实质性罪恶。如果具有这种危险，那么国会便有权予以防止。而这这是一个是否迫切程度的问题。但国家在战争期间，许多平时可以容许的言论因其妨害作战，不能不予以限制……”

【丹尼斯诉合众国案（1948年）】（确认）

1940年，美国国会通过了史密斯法，即所谓的外侨登记条例。该法的宗旨在于防止战时法西斯的间谍活动。内容包括禁止出版或散布号召推翻政府等材料等。

1948年7月，美国政府依该法逮捕了丹尼斯等美国共产党中央委员会委员，控告他们散布了阴谋推翻美国政府的煽动性言论。联邦地区法院和上诉法院仅对丹尼斯等人处以了罚款和监禁。但是，丹尼斯等人否认对他们的指控并向联邦最高法院提起上诉，理由是他们并没有主张以武力推翻政府，并认为史密斯法违反了宪法第1条言论自由的保护，因此请求法院宣告该法违宪。

联邦最高法院援引并发展了判例中已形成的“明显而即刻的危险的标准”，并据此作出了驳回判决，维持有罪判决。他们认为美国共产党的言论对于国家安全已构成了巨大而潜在的危险，政府不能暴乱发生时才采取行动，而应立即予以制止。

【焚烧国旗案（1984年）】

关键：詹森等人烧国旗的行为如何定性？——如果单纯定义为行为，有罪；如果定义为言论自由，则涉及到宪法第一修正案的言论自由。

联邦最高法院最终以5:4的比例维持了德州刑事上诉法院的判决

多数意见：第一修正案是一项基本原则，政府不得因为社会发现某种观念本身令人生厌或不合人意，就去禁止人民去表达这种观念。维护国旗之特殊地位的合适方法，并非是去惩罚那些对国家事务有不同想法的人们，而是去说服他们看到自己的错误我们惩罚并不能使国旗变得神圣。

少数意见：美国国旗是体现国家的明显象征，它既不代表任何特定政党的观点，也不代表任何特定的政治哲学。简言之，国旗并非一项‘观念’，被告行为根本够不上受第一修正案保护的言论。

（2）构成公共官员诽谤的原则

第一，政府官员必须证明被告的陈述带有“实际恶意”，即被告明知陈述是错误的。

第二，政府官员只能活得损害赔偿。

【批评官员的尺度】1960年3月23日，《纽约时报》接到一个支持马丁·路德·金的民权组织的一份广告，该广告呼吁民众支持并资助马丁·路德·金领导的黑人平权运动。1960年3月29日，《纽约时报》配以巨型大写字母的“关注他们高涨的呼声”(Heed Their Rising Voices)标题，刊登了这一广告。

广告谴责南方几个地区对黑人平权运动的压制，并且指责阿拉巴马州蒙哥马利市的警察“包围”了一所黑人学校，旨在镇压他们的和平示威，指责“某些南方违法者”曾经用炸弹袭击马丁·路德·金的家，殴打金本人；警察局先后7次以“招逮”、“闲逛”等莫须有的罪名逮捕金，还指控金“作伪证”。其中有些指责是缺乏事实依据的。

蒙市的公共事务专员沙利文看到报纸以后，向阿拉巴马州蒙哥马利郡巡回法庭提起诉讼，他的诉讼理由是：广告不指明提及的“南方违法者”指的就是他，因为他是事件发生时负责警察工作的市专员。他认为，该广告中涉及的失实内

容将在公众脑海中形成对他形象不利的印象——这一指控甚至得到当地民众的证词因此广告侵害了他的名誉权，沙利文要求法院判决纽约时报向他赔偿50万美元。

1960年11月3日，沙利文的这一诉讼请求获得了巡回法庭的支持，法官判决纽约时报应当向沙利文赔偿50万美元，这一判决于1962年8月30日再次获得阿拉巴马州高级法院的支持，州法院遵循普通法的惯例，认为当言论造成他人的声誉、职业、交易、商业活动都损失时，该言论即构成诽谤。

纽约时报不服两级法院的判决，上诉到联邦最高法院。1964年1月6日，联邦最高法院开庭审理此案，3月9日，联邦最高法院作出判决，他们认为利文没有足够的证据证明纽约时报出于恶意诽谤沙利文，尽管广告内容存在失实问题，9位大法官以9:0的投票结果一致通过推翻阿拉巴马州法院的判决。

布伦南(Brennan)大法官代表法庭阐述判决理由，他指出本案的价值在于“公共官员因其公务行为受到批评--这种批评正是宪政制度为了限制政府权力而保护言论与表达自由的反映--该批评是否该遭到因反对而提起的诽谤诉讼，本案第一次要求我们确定彼此的边界。

宪法对言论自由的保护并不取决于“人们发表的观念和信仰是否是真理、流行或者具有社会效用。…在自由辩论中，错误的陈述是不可避免的:要使表达自由获得所需的‘呼吸空间’，我们必须忍受这些错误。

在判决意见第二部分的最后，布伦南法官精彩地阐述了著名的“实际恶意”原则以及公民批评者赔偿豁免权的法理依据。

(3) (普通民众) 构成民事诽谤的规则

根据言论自由的身份的不同，保护程度也不同。

第一，诽谤性言论应当是错误言论；

第二，虚假言论是否因恶意或疏忽而起，都无关紧要；

第三，权利受到侵害的当事人不需要证明自己名誉权所蒙受的事实上的损害；

第四，或者惩罚性赔偿。

· 普通民众构成民事诽谤是很容易的

(二) 监督权与请求权 (要看——判断改错、选择)

宪法第41条

(三) 选举权与被选举权 (公共参与权利体现的主体性权利)

I 选举权和被选举权的含义

II 选举权与被选举权的宪法规定

第三十四条 中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

III 我国选举法的制定及修改情况

V 我国选举权与被选举权的基本内容

1. 选举权与被选举权的保护与限制

(1) 保护：法律保障与物质保障

(2) 限制：限制条件的设定

中国公民；年满18周岁；没有剥夺政治权利

· 政治权利的剥夺只能通过刑法（剥夺政治权力：刑法上的附加刑）（剥夺条件相当苛刻）

2. 选举权的行使★★★（案例、法条分析题-34、选举法一人一票原则等）（自学）

(1) 选举权行使的基本原则

普遍性原则

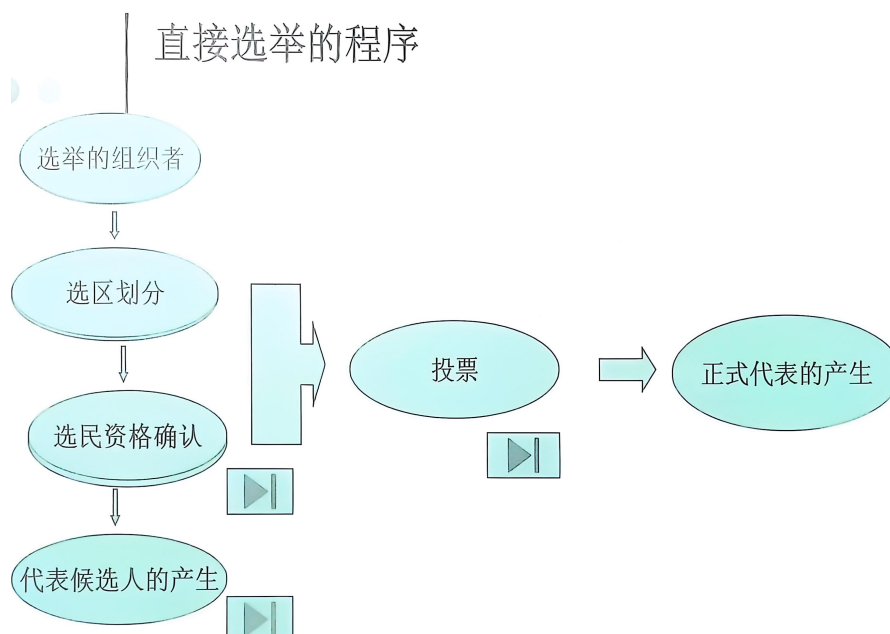
平等性原则

直接选举与间接选举相结合的原则

无记名投票原则

(2) 选举权行使的基本程序

① 直接选举的程序★★（大量的选择题）



· 选举的组织者：

临时组成；

根据选举法第九条成立选举委员会；

下面*均为组织者职责：

· 选区划分*

划分标准：选举法第二十五条第1款（多项选择题）——核心标准：居住状况；

划分数量：按照人口数划分选举法第二十五条第2款

· 选民资格确认*

需选民登记 选举法第二十七、第二十八条

选民资格维权 选举法第二十九条

· 代表候选人的产生：推荐——正式确定

选举法第三十条、第三十一条

· 投票

选举法第四十、四十一、四十二条

什么票是废票 选举法第四十四条

选举有效（step 1 选区过半数参加）+成功当选（step 2 参加者过半数）

选举法第四十五条

② 间接选举的程序

（四）宗教信仰自由（不考）

四、公民人身权利的保护

（一）人身自由★★★★（案例分析）

让人有尊严地幸福生活，

让人感到安全可靠，

让社会充满公正，

让人对未来充满信心。

——温家宝

· 与选举权与被选举权不同，人身自由是公民生来就拥有的权利。

I 我国宪法已规定的内容（广义的人身自由）

1. 人身自由（狭义的人身自由）

《宪法》第37条（背） 中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

→ 外国公民也受到保护 — 根据国际法的「国民待遇」原则，除了特殊权利，如选举权和被选举权「属于国家主权的问题，不是人身自由的问题」

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

· 行动自由、身体健康、生命

(1) 何谓人身？

躯体。包含行动自由也包含身体健康，包括肉体的生命（生命权就在37条）。

(2) 何谓自由？

i 不受非法逮捕

ii 不受非法搜查

iii 不受非法拘禁或以其他方式非法剥夺或者限制人身自由

(3) 我国对限制人身自由强制措施的规制★★★★★ (背背背)

i 限制人身自由的依据合法

依据：法律（狭义-全国人大及全国人大常委会）（绝对法律保留）；

国务院不可以用行政法规限制公民人身自由 《立法法》第十条规定了只有全国人大及常委会有立法权，并在第十一条规定了只能制定法律的事项（法律保留「事情保留给谁做」）。

《立法法》第十二条（背-用作论述）（区分了绝对法律保留和相对法律保留） 本法第十一条规定的事项尚未制定法律的，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，|但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外（该四项属于绝对法律保留）。

→所以此处对人身自由的限制只能由全国人大及常委会

ii 限制人身自由的目的正当

目的：第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

III 限制人身自由的主体有权

主体：人民检察院、人民法院、公安机关

《宪法》第37条第2款 任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

· 【讨论】现实中监察委员会也有限制人身自由的权利——留置权（max六个月，必要时可以再延长）

（考察和宪法一不一致时，为了保障法的统一性，应尽量进行合宪性论证）

监察委员会的留置权来自于监察法，即来自于全国人大常委会。相当于全国人大授权给监察委员会。但此处相当于全国人大通过基本立法的形式，对宪法第37条进行扩大解释。这种设定可倾向于合宪，但是期待后面进行更完备的处理。

iv 限制人身自由的程序合法

程序：（只有足够的程序保障，才能说实体权利有实现的可能）

V 违法或者非法侵害的，国家负赔偿责任

【孙志刚案设问】

1. 涉及的是什么样的宪法权利？

人身自由（最核心）、生命权、人格尊严…

2. 限制此宪法权利的法定内容有哪些？

依据、目的、主体、程序

3. 本案涉及限制此宪法权利的依据是什么？

《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》，国务院设立，属于行政法规，并不是狭义法律。

4. 依据是否合宪？若不合宪可依几种方式解决？

不合宪。立法法第11、12条

全国人大常委会（不是全国人大）可撤销。撤销的方法就是：按照立法法，提出建议……

2. 人格尊严（yyr：唯一的绝对权）（选择题、判断改错题）

(1) 含义

(2) 宪法规定

“人人生而自由，在尊严与权利上一律平等”——《世界人权宣言》第一条

“人的尊严不受侵犯。尊重和保护人的尊严是全部国家权力的义务”。——《德国基本法》第一条

《宪法》第38条（背）中华人民共和国的公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

→“任何”：合法或非法都不能侵犯公民的人格尊严。

· 设立时间：第38条的人格尊严条款在中国宪法上是1982年。

(3) 人格尊严保障条款的效力（看书）

i 立法

ii 行政

iii 司法

3. 住宅安全（属于广义的人身自由，自己看，熟悉条文，判断改错）

《宪法》第39条 中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

(1) 住宅安全的含义 (保护的是合法居住的空间的自由—本质是隐私权)

住宅: 居住的空间, 不论空间的合规与否、样态等。

保障的是空间的隐私权 (自由权)

i 住宅不得非法侵入

ii 住宅不受非法搜查

iii 不受其他方式的侵犯

(2) 住宅安全的保障

i 合法的搜查

ii 合法的检查

iii 侵犯居住自由的刑事与行政责任

4. 通信自由与通信秘密 (属于广义的人身自由, 自己看)

《宪法》第40条 中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要, 由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外, 任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

→“受法律的保护”: 用于积极的权利; “不受侵犯”: 用于消极的权利

(姚岳绒: 应该改成不受侵犯, 因为通信自由与通信秘密的权利不应该是积极权利。)

II 宪法隐含的内容

1. 迁徙自由

保护的不是行动自由, 而是保障成为那个城市的人。

2. 隐私权

3. 信息自由

姚: 宪法中公民存在信息自觉权

五、公民经济、社会、文化权利的保护

《宪法》第42条

(一) 社会经济权利

1. 财产权

(1) 我国宪法对财产权的规定及演变 (背, 可以看看书)

总体上: 范围扩大; 力度明确

· 1954年宪法第11条 国家保护公民的合法收入、储蓄、房屋和各种生活资料的所有权。

→ 范围: 保护的是“生活资料”, 因为是计划经济, 不允许有“生产资料”。

· 1982年宪法第13条 国家保护公民的合法的收、储蓄、房屋和其他合法财产的所有权。

→ 范围：生活资料变成“其他合法财产”，此时包含生活和生产资料。因为1982年宪法中允许个体经济拥有生产资料（个人即家人掌握少量生产资料，并可以出卖给他人）。

· 2004年修正

《宪法》第13条 公民的合法的私有财产不受侵犯。

国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

→ 范围：从列举到“合法私有财产”：体现了宪法对于公民财产权的扩大，用最抽象的方式保障公民的私有财产。所以此处只要是个人的私有财产，不论有形无形、生活生产…未来可能存在的一切财产样态，都受到宪法保护（如果出现新财产样态，会出现一段时间的“是否属于财产”的争论）。

(2) 现行宪法对我国公民财产权的保护

(3) 现行宪法对我国公民财产权的限制★★★（背）

理解：三条件缺一不可，若任一欠缺都不可构成对公民财产权的限制。

① 公共利益需要

→ 什么是公共利益：

· 只是性质上的判断，不是量上的判断——并不是套用公共利益，个人利益就可以无条件退让。

· “公共性”如何判断：征收一块地作私立医院（？）-虽然医院/学校是私立的，但是其本身就带有公共性

· 操作上如何判断：法律和行政法规列举出的公共利益

② 依照法律

→ 法律是狭义还是广义的：狭义的。

立法法中法律保留有非国有财产，所以对非国有财产的征收征用是法律保留，故此处的“法律”一定是狭义的。但是系相对的法律保留，所以可以由全国人大授权给国务院，先行制定行政法规。| 未来的趋势一定是上升到法律的形式更好。

③ 给予补偿

→ 没有说“合理”补偿：应然上没说，但是实然上要合理。

→ “合理”的标准：？

(4) 围绕征地现象，结合宪法，理性探讨我国公民财产权的保护与限制问题

2. 劳动权

(1) 劳动权的宪法规定

第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。

国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。

劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。

国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。

· 既是权利，又是义务（同教育权）

→ 设定成义务，但是不劳动不犯法？——设立条文时是公有制经济体制 + 按劳分配。此时禁止不劳而获。 | 但是现在是按劳分配为主，多种分配方式并存。所以现在不劳而获没有问题。

(2) 劳动权的内容（**不仅包含劳动的机会，还有劳动相关的内容**）

① 自由择业权

② 获得报酬与福利权

③ 休息权

第四十三条 中华人民共和国**劳动者**（不是“公民”）有休息的权利。

国家发展劳动者休息和休养设施，规定职工的工作时间和休假制度。

→ “劳动者”而不是公民：因为对于不劳动的公民而言，休息是自由。——休息对劳动者是right而不是自由，也不能因为休息扣劳动者的工资。

④ 劳动保护权

⑤ 职业培训权

⑥ 参与民主管理权

(3) 反就业歧视（缅怀蔡定剑教授）——**重心在平等**（案例题）

3. 获得社会保障权★（小题目）

第四十五条 中华人民共和国公民在**年老、疾病或者丧失劳动能力**的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。

国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优待军人家属。

国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。

· 物质帮助是权利right（**必须要有+受法律保护——不帮就是违法的**）：意味着遭受重大灾害而给予的物质帮助不是社会保障权。

（二）教育文化权利

1. 受教育权

第四十六条 中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

· 教育也是义务。义务的对象是**国家、社会 and 监护人（不是个人）**，是国家、社会 and 监护人有义务提供受教育的权利。

2. 科学研究自由

3. 文学艺术创作自由

4. 其他文化活动自由

· 其他法条：

第五十条 中华人民共和国保护华侨的正当的权利和利益，保护归侨和侨眷的合法的权利和利益。

→ “正当”-华侨-居住在中国境外的中国人：在他国受他国法律的约束

“合法”-归侨和侨眷-回来的中国人：受中国法律保护

第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

→ 理解权利和自由关系的原则和精神

专题五 宪法权力篇

(对应第三章和第四章)

· 先讲制度，再讲机构——制度是框架，国家机构是载体

一、国家与国家性质（本质：讲国体）

（一）国家要素与国家象征

1. 国家三要素

(1) 居民

(2) 领土

(3) 主权（对外+对内）：对外主权就是管辖权；对内主权就是政权。

* 三要素还是四要素的区分就在于对主权的理解

2. 国家象征（属于宪法问题）

第四章 国旗、国歌、国徽、首都

第一百四十一条 中华人民共和国国旗是五星红旗。

中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》。

第一百四十二条 中华人民共和国国徽，中间是五星照耀下的天安门，周围是谷穗和齿轮。

第一百四十三条 中华人民共和国首都是北京。

(1) 国旗

· 使用上，国旗代表国家主权（在外）

(2) 国歌

· 将国歌写入宪法是2004年。2004年之前被称为“代国歌”，因为制定宪法时将该歌作为国歌存在争议。

(3) 国徽

· 使用上，国徽代表国家政权（在内）

(4) 首都

（二）国家性质（基本制度中的决定性制度）

“国体，就是指社会各阶级在国家中的地位”——毛泽东：《新民主主义论》

1. 国体/国家性质（power的归属）：人民民主专政制度

第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。

→ “人民民主专政”：国家权力属于人民。即人民是国家的统治力量，被统治的是敌人

2. 人民民主专政的构成——“人民”的范围：（参见宪法序言爱国统一战线）

- 工人阶级（领导阶级）
- 农民阶级（阶级基础）
- 知识分子（工人阶级的组成部分）
- 其他社会主义事业的建设者
- 拥护社会主义、拥护社会统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者

* 宪法发展变化中，“人民”的范围越来越大。如“其他社会主义事业的建设者”是2004年宪法加入进去的，是指私营企业主；2018年对最后一类人作出修改，加上了“致力于中华民族伟大复兴”，扩大了范围，指的是香港、澳门、台湾和国外的。

- 镇压的对象：敌对势力与敌对分子（专政的对象）

* 违法犯罪的人不一定是人民（没剥夺政治权利的人还可以选人民代表，当然是人民），只有剥夺政治权利的人才一定不是人民。

【思考】工人阶级是依赖机器大生产的，没有土地；农民有土地

(1) 国家主席属于以上那一类？属于工人阶级和一般工人阶级一样吗？

(2) “农民工”是工人阶级还是农民阶级？作为农民又在城市依赖机器生活，作为工人却拥有土地

→ 反思：用阶级来分“人民”会遇到现实中没法解释的问题。在实务中按照「阶层」（政治、文化资源等等）分类，按照资源拥有量的差异进行划分（社会学热研究）。

见陆学艺：当代中国社会资源研究报告；中国社会阶层“9层金字塔”

* 社会阶层之间流动性越高，国家的活力越强。（阶层固化越明显，社会流动性越差，底层人民越没有希望）

3. 如何理解人民民主专政和无产阶级专政的关系

我国现行宪法序言规定：“工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政，实质上即无产阶级专政”

共同点：

- (1) 都以马克思主义为指导思想
- (2) 都是坚持工人阶级的领导
- (3) 都以工农联盟为阶级基础
- (4) 都行使同样的国家职能
- (5) 都赋有同样的历史使命

二、经济制度与文化制度

(一) 经济制度

第六条 中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能、按劳分配的原则。

国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

→ 经济制度：公有制为主体，多种所有制经济共同发展

(自学我国从82-2014年四次修改 经济制度是怎么调整的，看出什么趋势，什么问题)

→ 公有制两种形式：国有经济+集体所有制经济 (判断哪些是国有的，哪些是集体的)

| ——涉及我国自然资源的归属问题：

第九条 矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有；由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。

国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。

第十条 城市的土地属于国家所有。

农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。

任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。

一切使用土地的组织和个人必须合理地利用土地。

(1) 一定是国有的，不可能私有

(2) 矿藏、水流、城市的土地绝对归国家所有；宅基地和自留地、自留山绝对归集体所有

(3) 自然资源：法律没有规定的，归国家所有；

土地：农村和城市郊区的土地，法律没有规定的，归集体所有。

两个村就一条河流产生的争议，应找当地政府解决，因为河流归国家所有 |

1. 全民所有制 (国家经济)

2. 集体所有制

3. 非公有制 (多种所有制)

包含外资经济、股份经济等等等

(二) 文化制度

三、国家权力及其配置★★★

★★★一定会考政治制度★★★★★综合题——第四章第一节

1. 国家权力配置（国家权力的使用问题）的两种方式

人民享有国家权力，但是并不由人民直接行使国家权力

(1) 政权组织形式（政体）：横向·将国家权力分为：立法行政司法监察；权力的分工和制约

(2) 国家结构形式：纵向·将国家权力分为中央和地方。地方分为省市县乡四层政权（*村不是政权所在地，而是群众性自治组织）



议会制德国、总统制美国、半总统制法国、委员会制瑞士、人民代表大会制度社会主义国家。

(一) 我国政权组织形式：人民代表大会制度

1. 我国政权组织形式：

《宪法》第2条 中华人民共和国一切权力属于人民。

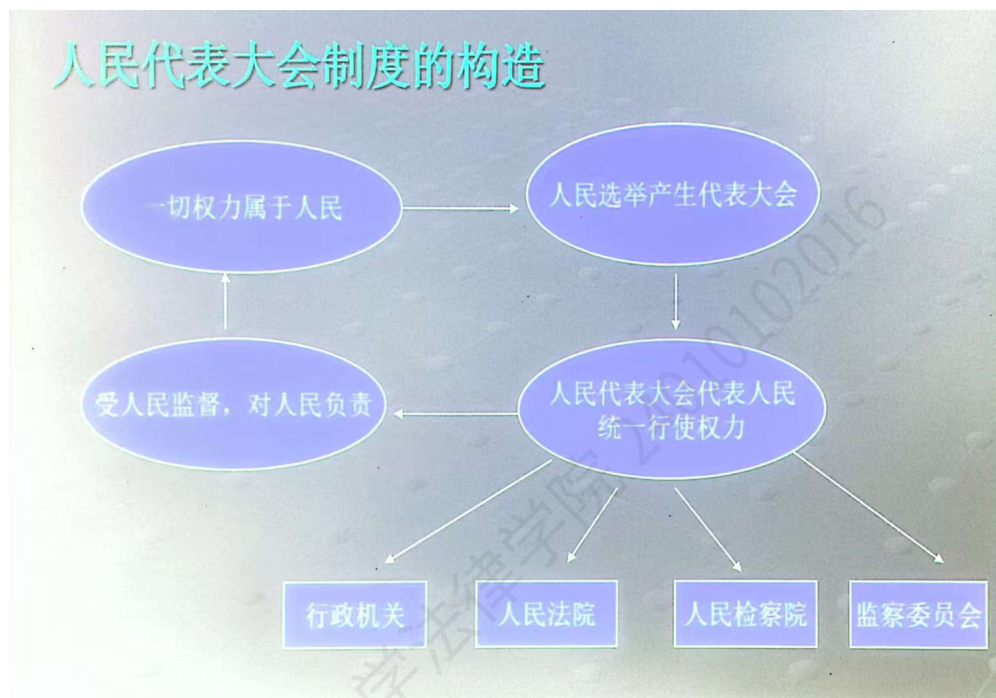
人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

【小结】我国根本社会制度——社会主义制度；我国最根本的政治制度——人民代表大会制度；我国根本经济制度——公有制为主体，多种所有制并存。

(2) 【描述人大制度】（描述人大制度·背）

四要素不能少，首先一切权力属于人民，人民选举产生代表大会，代表人民行使权力，人大受人民监督对人民负责的根本又回到一切权力属于人民。我国国家机构均由它产生对它负责受它监督——隐含着我国权力配置的原则，即民主集中制原则。

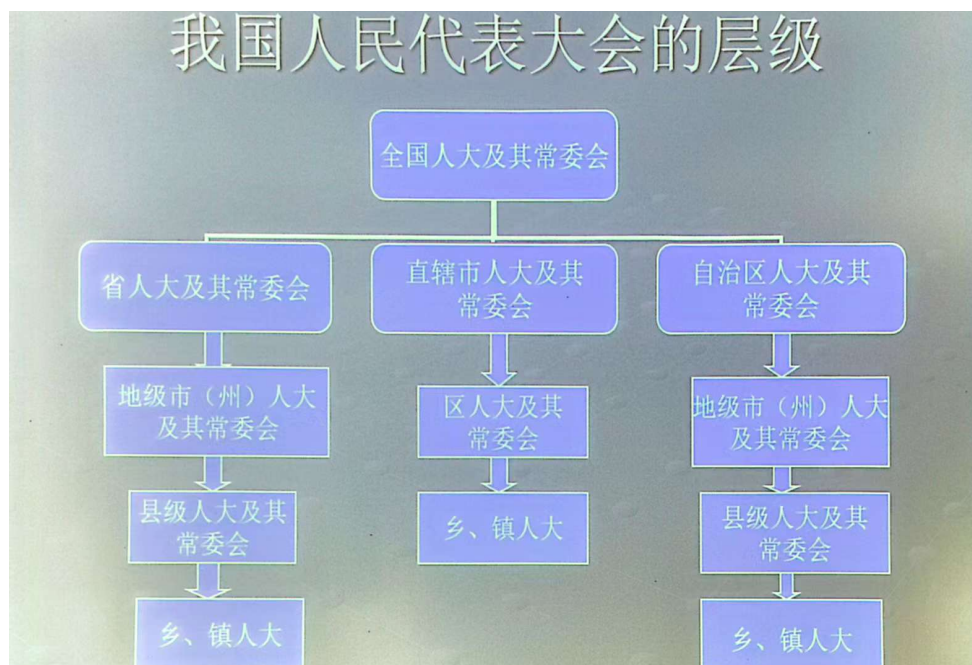


(2) 人大制度的地位：我国根本政治制度

(3) 人大制度的基本原则：民主集中制

2. 了解这个制度核心是要了解人大

(1) 层级



- 人大常委会是人大的组成部分，共同行使权力
- 最基层的人大没有常委会（乡镇），由主席团处理闭会期间的的事情。

(2) “两会”=全国人民代表大会+中国人民政治协商会议

同时举行但性质不一：全国人大是国家机关；政协不是国家机关，不行使国家权力（所以宪法不规定）

(3) 全国人大代表

由省一级人大代表选出（省人大）——区一级人大代表选出

* 如果是县级市、乡那就是直接选举产生

(4) 人民代表大会期间事务

① 常规工作：听取和审议六个报告（政府工作报告、人大常委会报告、年度计划报告、年度预算报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告）

【问题】为什么检察机关不做报告

② 审议重要法律草案

3. 全国人大（P216）

(1) 性质与地位

最高权力机关、最高立法机关、最高民意代表机关

(2) 组成与任期

全国人大由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。

代表任期五年，可连选连任

(3) 职权

第六十二条 全国人民代表大会行使下列职权：

- (一) 修改宪法；
- (二) 监督宪法的实施；
- (三) 制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律；
- (四) 选举中华人民共和国主席、副主席；
- (五) 根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选；
- (六) 选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；
- (七) 选举国家监察委员会主任；
- (八) 选举最高人民法院院长；
- (九) 选举最高人民检察院检察长；
- (十) 审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告；
- (十一) 审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告；
- (十二) 改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定；

- (十三) 批准省、自治区和直辖市的建置;
- (十四) 决定特别行政区的设立及其制度;
- (十五) 决定战争和和平的问题;
- (十六) 应当由最高国家权力机关行使的其他职权。

① 修宪权

② 立法权

全国人大制定基本法律; 全国人大常委会制定一般法律。

③ 国家工作人员的任免权

决定中央国家机关领导人方式: 选举 (有候选人) & 决定 (提名)

④ 重大事项决定权

⑤ 最高监督权

法律监督: 监督宪法实施; 有权改变或者撤销其常务委员会制定的不适当的决定。

工作监督

(4) 工作方式: 会议

提出议案——审议——表决——公告

4. 全国人大常委会 (P223)

(1) 性质与地位

① 性质: 权力机关、立法机关

② 地位: 是全国人大的常设机关, 在全国人大闭会期间行使最高国家权力的机关。在中央国家机关中, 地位低于全国人大, 高于其他国家机关。

(2) 组成与任期

委员长、副委员长、秘书长、委员

5年, 除委员长、副委员长连续任职不得超过两届外, 其余可以连选连任

(3) 职权

第六十七条 全国人民代表大会常务委员会行使下列职权:

- (一) 解释宪法, 监督宪法的实施;
- (二) 制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律;
- (三) 在全国人民代表大会闭会期间, 对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改, 但是不得同该法律的基本原则相抵触;
- (四) 解释法律;
- (五) 在全国人民代表大会闭会期间, 审查和批准国民经济和社会发展规划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案;
- (六) 监督国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作;
- (七) 撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令;

(八) 撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议；

(九) 在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选；

(十) 在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；

(十一) 根据国家监察委员会主任的提请，任免国家监察委员会副主任、委员；

(十二) 根据最高人民法院院长的提请，任免最高人民法院副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长；

(十三) 根据最高人民检察院检察长的提请，任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免；

(十四) 决定驻外全权代表的任免；

(十五) 决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除；

(十六) 规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度；

(十七) 规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号；

(十八) 决定特赦；

(十九) 在全国人民代表大会闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布；

(二十) 决定全国总动员或者局部动员；

(二十一) 决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态；

(二十二) 全国人民代表大会授予的其他职权。

① 解释和监督宪法

② 立法权★★ (考·法条分析题10')

除了全国人大制定的基本法律以外的一般法律（由于立法法没有界定基本与一般法律，所以只能表述为“除了全国人大制定的法律以外的其他法律”）；闭会期间，对全国人大所制定的法律进行修改或补充；解释法律（法律解释具有法律效力，故属于立法权）（无“闭会期间”，则开会期间其也可解释法律）

③ 监督权

④ 人事任免权

均为决定产生，没有选举（因为并非民意代表机关）

有“全国人大闭会期间”条件—本来应该由人大产生

无“全国人大闭会期间”条件—本就是人大常委会自己的职权

⑤ 重大事项决定权

核心：紧急状态决定权 松江区紧急状态-由国务院决定

→ 紧急状态决定权牢牢掌握在中央手中，地方不可能享有决定权。

战争状态：人大宣布；闭会人大常委会宣布

和平状态：人大宣布；职权在闭会不下放

⑥ 全国人大授予的其他职权

(4) 会议制度和工作程序

(二) 我国国家结构形式：中国特色的单一制国家结构形式

分为单一制和复合制。联邦制（州通过联邦宪法给联邦权力）。

我国属单一制（中央领导地方，地方服从中央。地方的权力是中央给的）。但是单一制度下又有民族区域自治制度和特别行政区制度。

1. 单一制元素：行政区划（要知道“地方”有哪些）

(1)

第三十条 中华人民共和国的行政区域划分如下（1982 规定，但是目前发生很大变化）：

（一）全国分为省、自治区、直辖市；

（二）省、自治区分为自治州、县、自治县、市；

（三）县、自治县分为乡、民族乡、镇（* 乡镇是最基础的政权，没有“村”）。

直辖市和较大的市分为区、县。自治州分为县、自治县、市。

自治区、自治州、自治县都是民族自治地方。

第三十一条 国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

(2) 行政区变更的法律程序★★★（选择题）

全国人民代表大会批准省、自治区和直辖市的建置，决定特别行政区的设立及其制度；

国务院批准省、自治区和直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分；

省、自治区和直辖市的人民政府决定乡、民族乡、镇的建置和划分。

2. 特色1——民族区域自治制度（点名选择题）

在国家统一领导下，依照宪法和法律的规定，以少数民族聚居区为基础**建立民族自治地方，设立自治机关，行使自治权**，实现各族人民当家作主和管理本民族内部事务的一种政治形式。

(1) 自治地方：乡镇不设置自治地方，不设立自治机关。

(2) 自治机关：只有人大和人民政府——自治机关可以行使自治权

(3) 自治权（期末考试无）：自治立法权；**法律、政策变通执行自治权**；…

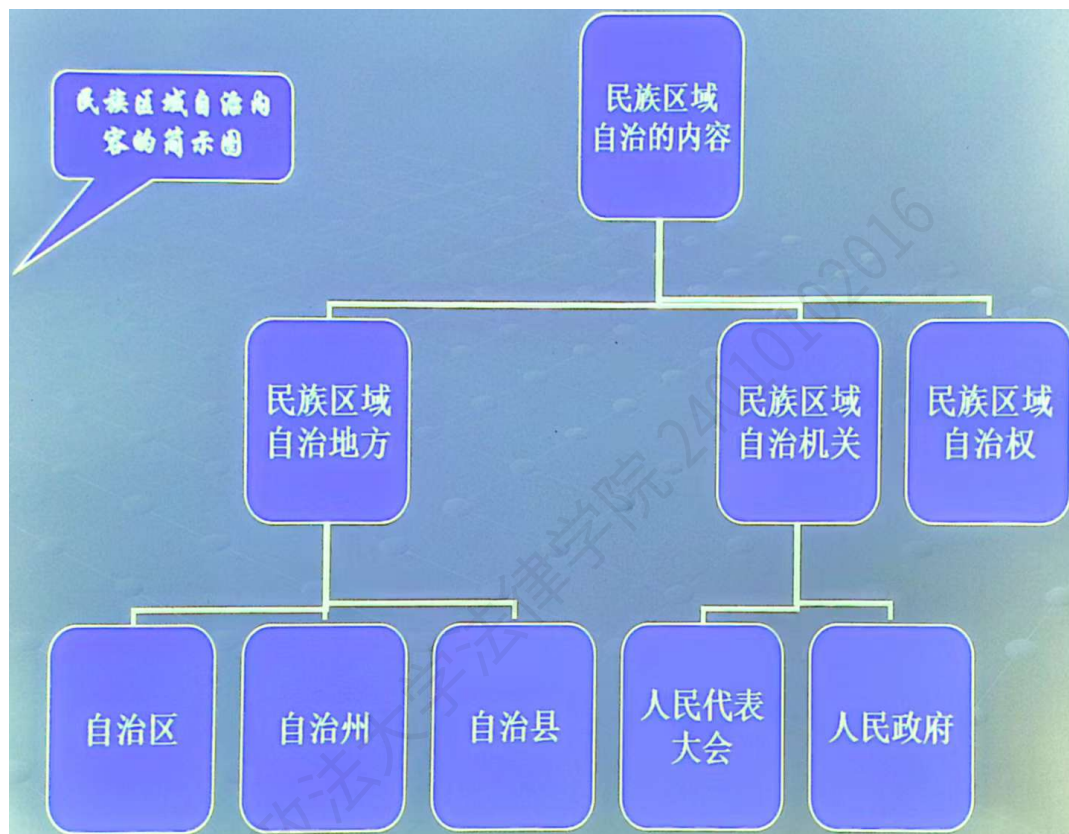
(4) 怎么确保自治权的实现：

在自治机关领导人的配备上：

《宪法》第113条 自治区、自治州、自治县的人民代表大会中，除实行区域自治的民族的代表外，其他居住在本行政区域内的民族也应当有适当名额的代表。

自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或者副主任。

《宪法》第114条 自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。



3. 特色2——特别行政区制度（第三章第七节+第四章）（选择题）

（1）特别行政区的法律地位：

地方行政区域——归中央管；享有高度自治权

《宪法》第三十一条 国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

香港、澳门基本法第1条都规定，特别行政区是中华人民共和国不可分离的一部分。

香港、澳门基本法第12条规定，特别行政区是中华人民共和国一个享有高度自治权的地方性行政区域，直辖于中央人民政府

（2）特别行政区制度下中央和地方的关系——核心：权力配置

① 中央对特别行政区的管辖权：负责外交事务；负责防务；任命行政长官及主要官员；紧急状态决定权；基本法修改权；基本法解释权

② 特别行政区享有的高度自治权：高度立法自治权；高度行政自治权；司法独立与终审权；高度的财政独立权；对外事务的处理权

(3) 特别行政区的政治体制

① 行政长官

双重法律地位：既是特别行政区首长，又是特别行政区政府（行政机关）的首长（类美国总统）。

【关键】中央和地方权力分配的关键，就在于行政长官如何产生。

任职条件

产生与任期

职权

② 特别行政区政府

③ 立法机关

④ 司法机关

四、政党制度

（一）政党与宪法

1. 政党的性质（选民和政府的桥梁关系）



* 各国共识：政党的组织不是国家机关（考试），如我国的政治协商会议（但是是爱国统一战线的组织形式）

2. 政党的宪法地位

(1) 宪法明确规定政党的地位

(2) 制定专门的政党法

(3) 以其他法律的形式规定政党

(4) 以宪法惯例的形式明确政党的地位

（二）我国的政党制度

我国现行《宪法》序言规定，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。

1. 制度1-中国共产党的领导：政治领导、思想领导、组织领导

2. 制度2-多党合作：以中国共产党领导的8个民族党派——核心：合作关系

精神原则/方针：长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共

3. 制度3-政治协商

(1) 政治协商的组织：政治协商会议

(2) 政治协商会议的性质：爱国统一战线的组织

(3) 政治协商会议的职能：政治协商、民主监督、参政议政

五、群众自治制度（第四章）（不考）

华东政法大学法律学院 24010102016

专题六 国家机构篇

一、国家机构概述（第三章第一节）（一点不考）

唯一注意：国家机构是国家机关的总称。

【区分】行政法学习领域：行政机构是行政机关的内设机构，机关大于机构。但是宪法上，国家机构的概念大于国家机关的概念。

二、我国国家机构的组织活动原则（小题）

（一）民主集中制★（点名选择题）★

（判断国家机关做这件事是体现了民主or集中or民主集中）

民主基础上的集中，集中指导下的民主。

（二）法治原则✓

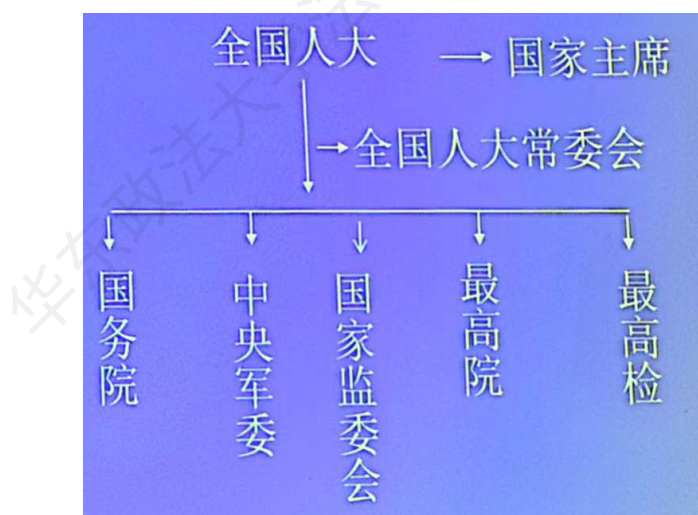
（三）责任制原则

（四）精简、效率原则

（五）为人民服务原则

三、我国国家机关体系

（一）中央国家机关



1. 国家主席

（1）性质：我国国家元首（宪法对国家主席的性质和地位没有明文规定，但是可以对其职权规定推出）。

（2）任期：5年一届；2018年删除“连续任期不得超过两届”。

（3）职权★（选择题）

核心：先要有 全国人大及其常委会的决定 → 国家主席职权为虚权

公布立法权；人事提名权与任免权；发布命令权；外事权（唯一的实权：进行国事活动，接受外国使节）；授予荣誉权

2. 国务院

(1) 性质与地位

性质上：行政机关、权力机关的执行机关

地位上：最高

(2) 组成与任期

组成：总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长等（银行行长和海关署署长也是）

任期：5年一届，其中总理、副总理、国务委员连续任期不得超过两届

组成成员的产生机制★（考）：总理是根据…（不是选举），全国人大闭会期间…

(3) 职权

（注意和全国人大交叉的职权，如紧急状态决定权、行政区划变更）

《宪法》第89条

(4) 国务院的领导体制：总理负责制（典型的个人负责制）

【区】全国人大及其常委会的领导体制：集体负责制

怎么体现总理负责★（可能选择题）：p239页

① 国务院总理人选由国家主席提名，经全国人大决定后由国家主席任命，总理担负着管理全国行政事务的职责，向全国人大及其常委会承担行政责任。

② 国务院其他组成人员的人选由总理提名，由全国人大或全国人大常委会决定，在必要时，总理有权向全国人大或全国人大常委会提出免除他们职务的请求。

③ 总理领导国务院的工作，副总理、国务委员协助总理工作，国务委员受总理委托，负责某些方面的工作或者专项任务，并且可以代表国务院进行外事活动。各部部长、各委员会主任负责某一方面的工作。他们均须向国务院总理负责。

④ 总理召集和主持国务院全体会议和常务会议，会议议题由总理确定，重大问题须经国务院全体会议或者常务会议讨论，总理在集体讨论的基础上形成国务院的决定。

⑤ 国务院发布的决议、命令和行政法规，向全国人大或全国人大常委会提出的议案，任免人员案，均须总理签署，才有法律效力。

(5) 国务院的组织结构（不考）

3. 中央军委

(1) 性质和地位：最高军事领导机关、武装力量领导机关

- (2) 任期：5年1届（宪法没有明文规定，也没有规定连续任期不得超过2届）
- (3) 领导体制：主席负责制
- (4) 职权（不考）

4. 人民法院

- (1) 性质：我国的审判机关
- (2) 组织系统：
分为四级-最高、高院、中级、基层（机构名称没有“基层”两个字）
- (3) 上下级关系：监督与被监督关系（上诉就是一种监督）
- (4) 法院的组成：院长、副院长、审判委员会委员..
组成成员产生：院长由人大；其他由常委会
任期：5年，最高法院院长连续任期不得超过2届
- (5) 审判原则：审判独立原则★（考）

5. 检察院

- (1) 性质：法律监督机关
- (2) 组织系统：
分为四级-最高；xx省人民检察院（对应高级）；xx市人民检察院（对应中级）；xx区人民检察院
- (3) 上下级关系：领导与被领导关系

6. 监察机关

- (1) 性质：监察机关
 - (2) 组织系统：
分为
 - (3) 上下级关系：领导与被领导关系
- 【注】人大上下级：监督与被监督关系；政府上下级：领导与被领导；村委会上下级：指导与被指导关系。

7. 分工（判断改错、选择）★

- (1) 普通刑事案件
第一百四十条 人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。
- (2) 监察委员会——普通的职务犯罪案件
第一百二十七条 监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

（二）地方国家机关（第三章）（不考）